

1522526-13.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 8ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/12/2022

... do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal (furto noturno) é aplicável tanto à forma simples quanto à qualificada do delito de furto. Essa orientação, vigente no tribunal até o momento, considerava entre outros fundamentos que a circunstância em que ocorre a causa de aumento de pena pelo furto noturno é compatível com o tipo penal furto, seja ele simples ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
8ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522526-13.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1522526-13.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Furto Qualificado (COVID-19)
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270037/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 27826988 - 24º D.P.
PONTE RASA, 2270037 - 24º D.P. PONTE RASA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FERNANDO NEVES SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

FERNANDO NEVES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos II (escalada), do Código Penal, porque, segundo a denúncia e seu aditamento, em 04 de outubro de 2022, por volta das 03h20 da madrugada, na residência situada na Avenida Aldeia Manuel Antonio, nº 313, Artur Alvim, Município de São Paulo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 1,5 m de tubulação de gás (aço), no período noturno e valendo-se de escalada. Recebida a denúncia, o acusado foi pessoalmente citado, apresentou defesa por escrito e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas a vítima, um testemunha e realizado o interrogatório do réu. Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentados, passo

diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial é procedente em parte.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), bem como pelas provas orais colhidas em Juízo.

A autoria do furto restou incontroversa, consignando-se que o réu foi preso em flagrante delito ao fugir com o bem subtraído.

Interrogado em juízo, o réu admitiu integralmente a prática do crime. Disse que, para acessar o imóvel, pulou o portãozinho do imóvel vizinho, de fotografia de fls. 137, caminhou até o fim do corredor e pulou o muro para o imóvel ao lado, da vítima. A confissão foi corroborada pela prova oral. Senão vejamos:

A vítima, Rinaldo Guimarães, relatou que estava dormindo em sua residência quando, por volta das 02 ou 03 horas da manhã escutou um barulho "estalo" no quintal. O depoente pegou sua arma e saiu para averiguar. Viu o réu pulando o muro, com uma barra de ferro de, aproximadamente, 1 metro, dobrada. O réu havia acabado de furtar a barra da instalação da Comgás. Tal barra fazia a ligação do condensador para distribuição de gás para a casa; ele havia desligado o gás antes de remover a barra. O depoente abriu o portão, foi até a rua, onde deu voz de prisão em flagrante para o réu. Solicitou apoio da viatura para conduzir o réu até o DP, onde a autoridade ratificou a voz de prisão em flagrante.

A testemunha Patrícia Queiroz Martins relatou: estava dormindo quando, por volta das 02:30 da manhã percebeu que seu marido não estava na cama e levantou para ver onde ele estava. Como a porta estava aberta saiu, oportunidade em que viu um rapaz junto a ele com uma barra de ferro que ele havia furtado. A barra de ferro era de uma ligação da Congás. O muro de sua casa tem 1,60m.

No contexto apresentado, os elementos de prova produzidos autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu efetivamente praticou o crime de furto descrito na denúncia. A qualificadora da escalada (inciso II) restou devidamente demonstrada pela prova colhida em Juízo, pela prova pericial (laudo a fls. 133/138), bem como pela confissão judicial do acusado, o qual admitiu que pulou o portão da casa do vizinho e o muro lateral para acessar o imóvel da vítima.

No mais, o delito se consumou, pois houve a perda, ainda que momentânea, da res furtiva. O acusado foi surpreendido na posse do bem, já em via pública, em local diverso de onde se deu a subtração.

Afigurar-se-ia imperiosa, também, em linha de princípio, a aplicação da causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), para cuja incidência "basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminoso, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime." (STJ, AgRg no AREsp nº 1.234.013, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.08.2018). Complementa VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES:

No passado havia consistente entendimento no sentido de que o furto noturno não deveria ser aplicado se o fato ocorresse em estabelecimento comercial fechado, com o argumento de que, em tais casos, o agente estaria se valendo da ausência de pessoas no local e não do sono dos moradores. Atualmente, entretanto, os julgados do Superior Tribunal de Justiça apontam em sentido contrário, autorizando o aumento da pena em razão da menor vigilância decorrente do repouso da coletividade. A propósito: "Incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes" (AgRg no REsp 1.582.497/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 15-8-2017, DJe 28-8-2017); "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que 'incide a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa

especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando' (HC 191.300/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes" (AgRg no REsp 1.546.118/ MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 2-2-2016, DJe 10-2-2016). É claro, porém, que, se o furto ocorrer em estabelecimento comercial aberto, onde existem pessoas trabalhando, não se aplicará o instituto. Também não incide se o fato ocorre em bares ou casas noturnas em funcionamento.' (Direito penal esquematizado - parte especial - 10. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 365). (Negritei).

Tendo sido o furto cometido antes do alvorecer (de madrugada), seria o caso de aplicar a causa de aumento em apreço. Todavia, vergando-me ao recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos recursos especiais repetitivos, de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, valorarei a majorante em tela como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, por se estar diante de furto na forma qualificada. Confira-se:

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP). Com a fixação da tese que marca uma mudança de posicionamento jurisprudencial do STJ, os tribunais de todo o país poderão aplicar o precedente qualificado em casos semelhantes. Não havia determinação de suspensão de processos com a mesma controvérsia. Relator dos recursos repetitivos, o ministro João Otávio de Noronha explicou que, em 2014, o STJ seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a entender que a causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal (furto noturno) é aplicável tanto à forma simples quanto à qualificada do delito de furto. Essa orientação, vigente no tribunal até o momento, considerava entre outros fundamentos que a circunstância em que ocorre a causa de aumento de pena pelo furto noturno é compatível com o tipo penal furto, seja ele simples ou qualificado, não havendo assimetria na conjugação desses dispositivos no momento da aplicação da pena. "Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto", afirmou. Entretanto, o ministro ressaltou que essa possibilidade de valoração do horário noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo, pois "a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador, na confecção da primeira etapa da dosimetria penal, é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais". (disponível em <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/02062022-Causa-de-aumento-pelo-furto-noturno-nao-incide-na-forma-qualificada-do-delito--define-Terceira-Secao.aspx>).

Nesse cenário fático-probatório, a conduta do réu se amolda, formalmente, ao disposto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o acusado registra cinco condenações criminais definitivas anteriores não alcançadas pelo período depurador, a saber: 0024154-39.2017.8.26.0050, 5ª Vara Criminal; 0029988-66.2018.8.26.0050, 2ª Vara Criminal; 0031886-42.2015.8.26.0050, 25ª Vara Criminal; 1514277-10.2021.8.26.0228, 3ª Vara Criminal; 1527559-86.2019.8.26.0228, 29ª Vara Criminal). Valoro quatro delas a título de maus antecedentes e a outra como reincidência, na etapa

posterior. Não obstante, o acusado também registra condenação definitiva caracterizadora de maus antecedentes (0043601-57.2010.8.26.0050, 1ª Vara Criminal). As circunstâncias do crime comportam maior reprovação social, porque cometido durante o repouso noturno. Assim, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e repouso noturno), majoro a pena-base em 3/8, passando a dosá-la em 02 anos e 09 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda etapa, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, de modo que a pena intermediária permanece no patamar anterior.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena final fica estabelecida 02 anos e 09 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal por não haver elementos que demonstrem ter o réu maior fôlego financeiro.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da benesse da suspensão condicional da reprimenda, dada a reincidência (arts. 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, a contrario sensu).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu FERNANDO NEVES SILVA, qualificado nos autos, às penas de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo os motivos justificadores da custódia cautelar, deverá continuar custodiado.

Recomendo, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA